

1500947-84.2019.8.26.0625
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Fato Atípico
Magistrado: João Carlos Germano
Comarca: Taubaté
Foro: Foro de Taubaté
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... gravadas do local.

Em se tratando de figura do furto qualificado, não se pode reconhecer o furto noturno, em razão do disposto no Tema 1.087, que enuncia:

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Quanto às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
3ª Vara Criminal
Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal
CEP: 12020-070 - Taubaté - SP
Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500947-84.2019.8.26.0625 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500947-84.2019.8.26.0625
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Bruno César Alves dos Santos

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Bruno César Alves dos Santos e Leandro Mateus Ferreira foram denunciados pelo Ministério Público porque, na madrugada dos dias 30.12.2018 e 7.1.2019, durante repouso noturno, na Rua Voluntário Benedito Sérgio, nº 1.895, B. Estiva, nesta cidade de Taubaté, agindo previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, um botijão de gás e dois “carrinhos de mão”, tudo avaliado em R\$ 540,00, de propriedade do estabelecimento denominado DEPÓSITO CASA NOVA, representada pelo seu proprietário Yasto Saiki.

Segundo apurado pela acusação, na madrugada do dia 30.12.2018, aproveitando-se da vigilância reduzida do estabelecimento vítima, os réus invadiram a loja material de construção e subtraíram um botijão de gás.

Não satisfeitos, na madrugada do dia 7.1.2019, empregando o mesmo modus operandi, na companhia de outros indivíduos não identificados, invadiram novamente o estabelecimento vítima e subtraíram dois “carrinhos de mão”.

Todavia, as ações criminosas foram gravadas pela câmera de segurança, ocasião em que foram reconhecidos nas filmagens levando os produtos subtraídos.

Busca, assim, a condenação dos réus como incursos no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida às fls. 294/296.

O réu Bruno foi citado pessoalmente (fls. 312) e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 319/320.

Quanto ao réu Leandro, por não haver sido encontrado, houve o desmembramento do processo.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas a vítima Yasto Saiki e a testemunha Martim Alves Gonçalves, procedendo-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Destacou que o réu Bruno foi beneficiado pelo acordo de não persecução penal, ocasião em que confessou o crime, embora o acordo tenha sido revogado por descumprimento das obrigações. Ouvidos em juízo, a vítima e a testemunha confirmaram os fatos e todas as circunstâncias. Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Por esses fatos, requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. Anotou que o réu foi reconhecido pelos moradores, bem como confessou anteriormente ter praticado o delito em parceria com o réu Leandro. Na dosimetria, ausentes circunstâncias especialmente desfavoráveis, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal. Para o cumprimento, pediu que seja fixado o regime aberto. Ademais, solicitou a aplicação da regra do crime continuado. Por fim, manifestou-se pela possibilidade de substituição da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, diante da fragilidade probatória. Discorreu que, tanto o proprietário quanto o funcionário disseram ter realizado o reconhecimento do réu pelas imagens da câmera de segurança, contudo, as filmagens acostadas nos autos demonstram a impossibilidade de reconhecimento de qualquer pessoa. Pontuou que, de acordo com o laudo pericial, as mídias apresentadas, que teriam sido gravadas por ocasião dos fatos, não evidenciaram o rosto dos autores do crime, inclusive porque, um deles estava com uma camiseta no rosto, sendo impossível verificar de quem se trataria. Outrossim, anotou que, ainda que se pudesse estabelecer as vestimentas utilizadas, é certo que as imagens estavam em preto e branco, inviabilizando a identificação por cor. Além disso, afirmou que as imagens não têm nitidez, embora apresentem diversos ângulos, e, na cena em que aparecem dois indivíduos, ambos estão de costas. A respeito do segundo delito, comentou que as imagens são somente do lado externo do estabelecimento, nas quais se visualiza uma pessoa passando na calçada, sem a garantia de que houve ingresso no imóvel. Defendeu, ainda, que os peritos destacaram um indivíduo correndo na via pública, que aparentava ser em frente ao estabelecimento vítima. Mencionou, por fim, que nenhuma das pessoas ouvidas estava presente, ou seja, não visualizaram pessoalmente o referido ingresso no depósito, assim como nenhum objeto foi recuperado, a fim de indicar a efetiva participação do réu. Caso o entendimento não seja este, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que os fatos não destoaram do normalmente esperado em situações semelhantes. Ademais, postulou o afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Subsidiariamente, solicitou o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, considerando sua

incompatibilidade com a forma qualificada do furto. Para o cumprimento de pena, pediu que seja fixado regime aberto, com substituição da pena por restritiva de direitos. Por fim, manifestou-se pelo reconhecimento da continuidade delitiva, com aumento no mínimo de 1/6.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento parcial do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de declarações (fls.17/20), boletim de ocorrência (fls.3/7), laudo pericial (fls. 29/47), auto de qualificação da vida pregressa (fls.123/125) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de furto qualificado.

A vítima Yasto Saiki, ouvida em juízo, relatou que os réus são conhecidos de seus funcionários e vizinhos, por morarem em ruas próximas. Em razão da incidência frequente de furtos no local instalaram um sistema de monitoramento por câmeras no imóvel. A partir disso, conseguiram capturar as imagens do crime. Alegou que os conhecia de vista. Posteriormente, conseguiu reconhecê-los pelas filmagens. Citou que, inclusive, o réu Bruno foi à Delegacia prestar depoimento usando a mesma camiseta utilizada no dia dos fatos.

A testemunha Martim Alves Gonçalves, ouvida em juízo, informou que é caseira do depósito. Ele e a família moram no terreno. Na ocasião, verificou as filmagens do delito e reconheceu os autores. Alegou que já os conhecia, pois moram perto de sua residência. Os objetos não foram recuperados.

O réu Bruno César Alves dos Santos, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Não se recorda de ter invadido o local. Acredita que tenha passado pelo endereço naquela data. Afirmou que conhece a vítima e a testemunha. Narrou que Martim foi até sua casa, posteriormente, acusá-lo do delito, motivo pelo qual acabou acertando-o com uma faca. Não sabe o motivo de estar sendo acusado. Negou que estivesse com a mesma roupa que o autor do crime, conforme dito pela vítima. Disse ser casado e tem 3 filhos; trabalha em uma fábrica de pneus, com renda média de R\$ 1.700,00; não tem outros processos.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 155, do Código Penal:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

...

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

...

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas."

Pelos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que se somam às provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, verifica-se que a conduta do réu encontra subsunção típica no artigo acima destacado, contudo, não se podendo reconhecer a figura do repouso noturno, ante a ocorrência da qualificadora.

A representante da vítima afirmou que conhecia o réu das proximidades e o reconheceu pelas imagens da câmera de segurança.

A testemunha Martin, em relato, firme e assertivo, alegou que mora no local como caseiro e já conhecia o réu, sendo que observou que o furto foi por ele cometido em razão das imagens captadas pela câmera de segurança.

As imagens traduzidas no laudo de fls. 29/47 dão conta do furto, inclusive que dois eram os furtadores.

A despeito de não se poder afirmar somente pelas imagens de que do réu se tratava, as demais provas, em conjunto, dão conta que o réu perpetróu o delito.

Ademais, há que se levar em conta a confissão do réu quando da realização do ANPP, oportunidade em que assumiu a autoria dos furtos em questão.

Assim, dúvida não existe acerca de como os fatos se passaram e que demandam a responsabilização do réu.

Nesse contexto, a comparsaria resultou evidente diante da confissão do réu, que também confirmou pelas imagens gravadas do local.

Em se tratando de figura do furto qualificado, não se pode reconhecer o furto noturno, em razão do disposto no Tema 1.087, que enuncia:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Quanto às teses defensivas, nenhuma delas é capaz de afastar sua responsabilidade.

A negativa do réu em Juízo demonstra unicamente que está mentindo acerca dos fatos, ante as demais provas nos autos obtidas, conduta censurável pois havia confessado a prática do delito em audiência anterior quando aceitou o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público.

A alegação de fragilidade probatória vai de encontro às provas produzidas nos autos e que bem comprovam os fatos.

Anoto que as imagens das câmeras se somam aos relatos da vítima e do funcionário, que não deixam dúvida acerca do reconhecimento do réu, ainda que no laudo a nitidez esteja comprometida.

Por outro lado, o fato de nenhuma das testemunhas terem visualizado o delito quando de seu cometimento não afasta o reconhecimento feito por meio das imagens gravadas, apontando para o réu sua prática.

O concurso de pessoas, por sua vez, foi apontado pelas imagens, assim como pela confissão do réu quando da aceitação do ANPP.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de

culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvidas de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Aferida a responsabilidade, passo à dosimetria da pena com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atentando-se ao critério trifásico de Nelson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Tenha-se por primeiro que foi reconhecida a qualificadora da comparsaria, sendo, então, adotada a pena prevista no §4.º, do artigo 155, do Código Penal.

Na detida análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, observo que a culpabilidade – que consiste na reprovabilidade da conduta – se mostra normal à espécie, nada havendo a se valorar.

O réu não possui maus antecedentes.

Não há nos autos elementos acerca da conduta social do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-la.

No que se refere à personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição, conduta que se revelou ainda mais censurável, pois em audiência anterior o réu confessou em juízo a prática delitiva por ocasião da audiência em que aceitou a proposta de acordo de transação penal. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica –, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do

Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexactidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade".

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para

exasperação da pena-base." (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

Os motivos do crime são os naturais à espécie, bem como as consequências são ordinárias, sendo, assim, neutras para o fim de fixação da pena.

A vítima não contribuiu para o delito.

Nesse passo, na fixação da pena-base, eleva-se a pena em 1/6, alçando-a a 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, há de se reconhecer a confissão do réu como atenuante utilizada para formação da culpa, tornando a pena ao mínimo legal, em razão do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há circunstâncias atenuantes, fixada a pena, então, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para cada um dos crimes.

Na terceira fase não há causas de diminuição ou aumento de pena, fixada, assim, definitivamente em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para cada um dos crimes.

Há que se reconhecer, contudo, hipótese de crime continuado. Isso porque os dois delitos se deram em questão de poucos dias e o modus operandi foi o mesmo, adequando-se ao disposto no artigo 71, do Código Penal, razão pela qual aplico a pena de um deles, porque idênticos, e aumento em 1/6, elevando-a para 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, pena que torno definitiva.

O regime inicial, diante da quantidade de pena, será o aberto, nos termos do artigo 33, §2.º, alínea "c", do Código Penal.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia-multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Observo que é o caso de se substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. A pena é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução, e pela limitação de final de semana.

Ante a substituição acima apontada, incabível a suspensão condicional da pena pelo artigo 77, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do processo esteve ele em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, prestigiando assim a presunção da inocência, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Como afirma Ricardo Schmitt, "como regra geral, temos que se o sentenciado se encontra solto, em liberdade plena no momento da sentença, tendo permanecido nesta situação durante a instrução processual, em princípio possui o direito de recorrer

em liberdade, salvo se existir algum motivo ponderoso à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou, em último caso, de decretação de sua custódia preventiva" (Sentença Penal Condenatória, 8.^a ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 443).

O réu não esteve por este processo, motivo pelo qual não se há falar em detração da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Bruno César Alves dos Santos à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, fixado o regime aberto como inicial de cumprimento da pena, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo a prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 2 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA